

1500712-87.2020.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA CASTRO ANDRADE SILVA

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... que naquele local estava acontecendo tráfico de entorpecentes. Em patrulhamento o acusado foi abordado em frente a sua residência. Realizada busca pessoal e nada foi encontrado com o mesmo. Questionado sobre o tráfico de drogas ele nada declarou. Perguntado se tinha mais alguém em sua casa o mesmo respondeu afirmativamente, dizendo que sua esposa se encontrava na residência. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

1ª Vara

Av. Monsenhor Ângelo Angioni, nº 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500712-87.2020.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500712-87.2020.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

GABRIEL HENRIQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE

GABRIEL HENRIQUE DA SILVA (fls. 19) foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (fls. 84/87).

Isso porque, segundo consta, em 18 de maio de 2020, por volta das 18h30, na rua Maria Decrescenzo Fachin, 54, Centro, nesta cidade e comarca de José Bonifácio, o acusado guardava e tinha em depósito, para fins de mercancia, 36,91 gramas de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, acondicionada em 07 (sete) invólucros plásticos, o que fazia em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Foi apresentado o seguinte rol de testemunhas: PM Henrique Pinto Chiareli (fls. 3) e PM Everton Moisés da Conceição Machado (fls. 4).

Preso em flagrante, o acusado recebeu liberdade provisória (fls. 49/50).

Recebida a denúncia (fls. 124), o acusado foi citado pessoalmente (fls. 139) e apresentou defesa prévia (fls. 120), por defensor nomeado (fls. 113), sem arrolar testemunhas.

O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 141/142), sendo realizada audiência de instrução.

As partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu absolvição por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A autoria e materialidade dos fatos restaram indiciariamente demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 9/11), termos de declarações, depoimentos e interrogatório (fls. 3/7), relatório final (fls. 81/82), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação (fls. 26/28), laudo pericial de exame toxicológico (fls. 77/79) e laudo pericial do aparelho celular (fl.90/104). Por sua vez, o contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório dá respaldo à acusação.

Conforme a denúncia:

Segundo se apurou, em circunstâncias que serão melhor aclaradas na instrução criminal, o denunciado obteve a substância ilícita acima mencionada e passou a mantê-la em depósito, com o fim de comercializá-la.

Na data dos fatos, o denunciado estava na frente de sua casa quando foi abordado por policiais militares que apuravam informação anônima de que ele estava praticando o tráfico de drogas.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, após terem o acesso franqueado pelo denunciado, os policiais conseguiram localizar, no interior de uma geladeira, 07 (sete) invólucros plásticos, com 40,39 gramas de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha".

Interrogado, o denunciado confessou prática do crime e relatou que vendia a droga aos usuários, após contatos feitos através do seu aparelho celular, que foi apreendido pelos policiais militares.

A companheira do denunciado (fls.05), por ocasião do flagrante, confirmou que o denunciado estava praticando o tráfico de drogas e para tanto utilizava o seu aparelho celular.

O material apreendido foi submetido a perícia que constatou a presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC), que se encontra descrita na lista F2 (Lista das substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e atualizações posteriores (laudos de fls. 77/79).

O modo de acondicionamento da droga apreendida, o local onde ela estava guardada, bem assim as condições em que se desenvolvia a ação criminosa e as circunstâncias da prisão revelam o inequívoco intuito de tráfico de drogas.

Foram apreendidos: sete trouxinhas de material plástico com aproximadamente 38,550 gramas de maconha e um telefone celular, marca Samsung, cor dourado, com a película/tela danificada, chip nº 17 991073025, modelo J2 Prime.

O laudo de constatação detectou a presença da substância tetrahydrocannabinol - THC na massa líquida de 36,91 gramas, contidas em 7 invólucros de plástico.

O laudo de exame químico-toxicológico definitivo apontou resultado positivo para: tetrahydrocannabinol - THC nas amostras colhidas de uma porção de fragmentos vegetais constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos.

O laudo, realizado no aparelho celular do acusado, constatou a traficância entre os dias 20/04/2020 e 18/05/2020 (dia do flagrante) pelas seguintes trocas de mensagens via WhatsApp: "tem o verde ainda?"; "Booa"; "É na rua do vito seu barraco né"; "Vo encostar aí já já"; "Chego a top"; "Original"; "Cade"; "Vae salva"; "Amais c quiser pega puc fuma"; "A top velinho"; "De verdade"; "Melhor do q akela q vc fumo akela dia"; "Tô colando"; "Ai chego a top homim"; "Pode pa homin"; "Qnto se fais aí uma cota daora pra min vende aki homin"; "350"; "Mais e a top homim"; "Então, só ia ver um pedacinho com cê mesmo, Veinho, pra mim fumá, tá ligado? Um pedacinho dá hora...Umas trinta grama, por aí!"; "Chegando do um salve"; "fexo homim agradece"; "Fala pra vc te uma"; "Top"; "C quiser faço 50g 200\$"; "Num pra faze um preço mais dhr vein pode manda hj dia 20 moeda tá na mao"; "Vou vê aqui ti dou um salve"; "aii clario uma fita"; "So que so amanha"; "Baep"; "Ta na cidade"; "joguei no mato"; "Vc vai querer"; "100g"; "Intao vein vó quere 50 g só pow pa fuma memo ai dia 20 moeda tá na sua mao já"; "Vein tenho so de 100g"; "Pow"; "350\$ avstia 400\$"; "400 no prazo"; "Vc pega 100g vende"; "50g"; "Por 200\$"; "E ai meno tem o cha"; "Tem, tem o chá sim. É só e constar aqui em casa"; "ai chego o top homim"; "Demro"; "Recebe do um salve"; "C quiser pega homim"; "Espero vc até dia 20"; "Pode cre vó v certim já do um"; "Salve"; "Fexo"; "Tu borracha"; "Tem homi"; "Cola"; "Pow"; "Até quarta";

"ai chego a top no peso vein"; "Qualquer fita da um slv"; "Demoro vein"; "quantas g 50\$?"; "A vein"; "Vó vê aki depois te falo certin" (fls. 90/103).

A testemunha PM Henrique Pinto Chiareli narrou que havia um grande número de pessoas fazendo denúncia de que naquele local estava acontecendo tráfico de entorpecentes. Em patrulhamento o acusado foi abordado em frente a sua residência. Realizada busca pessoal e nada foi encontrado com o mesmo. Questionado sobre o tráfico de drogas ele nada declarou. Perguntado se tinha mais alguém em sua casa o mesmo respondeu afirmativamente, dizendo que sua esposa se encontrava na residência. Questionado se havia droga em sua residência ele respondeu prontamente que sim, que a droga era dele e que sua esposa não tinha nada a ver com isso. A droga estava na geladeira e ele disse que, se quisessem, podiam entrar lá e pegar. Ele ficou com medo que sua esposa fosse comprometida com sua conduta. Natália, ao ser questionada sobre a droga, informou onde a mesma se encontrava. Natália declarou ao depoente que a droga era vendida por R\$ 50,00. Inicialmente o acusado foi visto na frente da residência. Não conhecia o réu mas tinha muitas informações de que naquele endereço, casa do réu, era praticado o tráfico de entorpecentes. No dia da ocorrência foi apreendido um telefone celular porque a Natália disse que ele comercializava drogas através de um aplicativo. Não se recorda se havia alguma quantia de dinheiro em posse do réu.

A testemunha PM Everton Moisés da Conceição Machado afirmou que durante patrulhamento encontraram o acusado defronte ao numeral. Quando foi realizada uma abordagem no mesmo nada foi encontrado com ele. Porém quando questionado sobre a possibilidade de ter drogas guardado em sua residência o acusado confirmou que havia e que estava guardada em um recipiente dentro de sua geladeira. Ele franqueou a entrada dos policiais em sua residência e lá foi encontrada a esposa do acusado. Perguntado a mesma se ela sabia se seu marido comercializava droga a mesma confirmou que sim, que ele vendia a quantia de R\$ 40,00 a R\$ 50,00. Autorizada pela esposa do réu, foi realizada a revista no local onde o acusado havia indicado, que era a geladeira, e lá encontraram a droga que foi apreendida. O local da abordagem é conhecido nos meios policiais como sendo local de tráfico de drogas e o réu foi abordado porque ele foi o único encontrado no local. Não conhecia o réu antes daquela abordagem.

O interrogatório restou prejudicado pela revelia.

Diante das narrativas oferecidas, concluo que o delito está efetivamente caracterizado, essencialmente, pelos fundamentos abaixo.

O local dos fatos é conhecido pela prática de tráfico e o acusado foi abordado em frente a sua residência, tendo assumido que havia drogas em sua casa e sua companheira estava ali para franquear a entrada, o que foi feito. A própria companheira do acusado acompanhou a busca da droga, encontrada na geladeira, e confirmou que o acusado vendia porções por R\$ 40,00 a 50,00 e inclusive por aplicativo. Ademais, as conversas encontradas no celular do acusado demonstram a venda de drogas pouco antes e no próprio dia do flagrante.

Cabe observar que é lícito o ingresso em domicílio mediante autorização do morador ou, mesmo sem mandado judicial, se houver fundados indícios da existência de flagrante delito (art. 5º, XI, da Constituição e art. 240 do CPP). Como o tráfico, na modalidade de guardar ou ter em depósito drogas, é crime permanente, sua consumação se prolonga no tempo, de modo que o agente se encontrará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 303 do CPC). Logo, no caso, não houve ilicitude ou abuso apto a acarretar a ilicitude das provas obtidas:

1. Durante a realização de diligência verificar a existência de indícios de crime após o recebimento de notícia anônima circunstanciada, a guarnição policial se deslocou até o local dos fatos. O agravante, por sua vez, ao avistar a viatura policial empreendeu fuga, no que foi seguido pelos policiais até que adentrou à residência. Diante da fundada suspeita da prática de crime, os milicianos adentraram à residência e lograram apreender significativa quantidade de entorpecente.

2. "Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais

adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida" (RHC 99.309/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/8/2018). (AgRg no HC 556.588/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

II - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

III - A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Precedentes.

IV - No caso dos autos, a entrada dos policiais não decorreu de mera "atitude suspeita" dos pacientes, porquanto, conforme consignado pelo eg. Tribunal a quo, os milicianos "realizavam patrulhamento de rotina" quando "os dois adolescentes, ao verem a viatura policial, correram para dentro do lote" e "diante da atitude suspeita, entraram no lote" (fl. 278), eventos por si só suficientes para configurar as "fundadas razões" para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Não obstante, soma-se a essa circunstância o fato de ter havido autorização para o ingresso na residência, visto que "a irmã de um dos adolescentes autorizou a entrada dos policiais na casa" (fl. 280). Habeas corpus não conhecido. (HC 540.714/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Vale dizer ainda que o simples fato de as testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer seus depoimentos, os quais devem ser valorados com isenção e em cotejo com os demais elementos probatórios:

Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Sequer há motivo para se imaginar que os agentes ou terceiras pessoas desconhecidas pretendessem incriminar o acusado falsamente, mesmo porque os policiais não o conheciam.

Por sua vez, a Defesa não conseguiu demonstrar a falibilidade dos depoimentos das testemunhas. Com efeito, não basta apenas argumentar que inexiste presunção de veracidade dos depoimentos dos policiais ou que não é possível presumir a culpa apenas porque a droga foi encontrada dentro do imóvel. É preciso ir além das teses, oferecendo-se explicação concreta para os fatos. A versão apresentada pelo acusado precisaria ser verossímil e não foi. Na verdade, a tese de Defesa pressupõe que a conduta dos agentes assumiu conotação abusiva ou que alguém desconhecido queria prejudicá-los, mas não há razão concreta e idônea que a sustente, pelos motivos já expostos.

Ressalte-se também que nada impede que a traficância ocorra em paralelo com o uso de drogas e/ou com o exercício de ocupação lícita, razão pela qual tais alegações não afastam a caracterização da conduta típica. Ademais, o art. 33, caput, da Lei 11.343/06 se caracteriza como tipo misto alternativo, de maneira que basta que o agente incorra em qualquer das condutas ali mencionadas, dentre elas a de ter drogas em depósito, sem autorização, como descrito na denúncia.

Logo, a conduta não está acobertada por causa excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, restando bem caracterizada a prática do delito.

Por tais motivos, a pretensão punitiva procede.

Passo à dosimetria.

Nessa tarefa, cabe observar o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

Nesse sentido, o Código Penal prevê que o patamar da pena deve ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59, caput).

Ademais, no tocante especificamente aos crimes previstos na Lei 11.343/06, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (art. 42).

Prevalece na jurisprudência que, por serem circunstâncias preponderantes e devido à vedação ao bis in idem, a natureza e a quantidade de entorpecente devem ser valoradas apenas na primeira fase da dosimetria e só podem ser usadas na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado se estiverem conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, que, unidas, caracterizem a dedicação do agente a atividades criminosas ou integração a organização criminosa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. O tratamento legal conferido ao crime de tráfico de drogas traz peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

3. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

4. No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena.

5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

6. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores “natureza e quantidade de drogas apreendidas” para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

7. A natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 687.767/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E

QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença. (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

O delito de tráfico de drogas é punido com pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto e a de detenção, em regime semiaberto ou aberto, conforme o montante aplicado (menor que 4 anos, maior que 4 anos e menor que 8 anos ou maior que 8 anos) e a presença ou não de reincidência e antecedentes (art. 33, caput e §2º, do CP, Súmulas 269 e 440 do STJ e Súmulas 718 e 719 do STF).

A pena de multa é calculada em dias-multa, sendo, no mínimo, de 10 e no máximo de

360 dias-multa (art. 49 do CP), segundo o critério trifásico previsto no art. 68 do CP.

O valor do dia-multa não pode ser inferior a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser considerada a situação econômica do réu (art. 60 do CP).

Na primeira fase, quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado é primário (fls. 182/183).

Quanto às demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade do ato praticado; conduta social e personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e comportamento da vítima), não devem ser valoradas negativamente, pois inexistem peculiaridades fáticas aptas a justificar a exasperação da pena-base.

Por sua vez, a natureza e quantidade de droga encontrada apenas corroboram a caracterização do tráfico, não justificando a exasperação da pena-base.

Consequentemente, a pena deve partir do mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes.

Presente a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), considerando que o acusado é nascido em 19/11/2001, que, contudo, não repercute na dosimetria, uma vez que a pena se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Consequentemente, a pena não se altera.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Presente a causa de diminuição de 1/6 a 2/3 prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando que o acusado é primário e inexistem indicativos de seu envolvimento em organização criminosa ou atividades criminosas, não bastando a quantidade de droga isoladamente para afastar o redutor: "Esta Corte vem decidindo que a quantidade de entorpecentes apreendidos, isoladamente não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, se dissociada de outros elementos de prova, para atestar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa" (AgRg no AREsp 1636928/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

Assim, inexistindo razões para maior rigor, cabe aplicar a maior fração de diminuição, ou seja, 2/3, o que resulta em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, o que a torna definitiva.

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

Pelo montante, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial aberto (art. 33, §2º, c, do Código Penal).

O acusado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que a pena não supera 4 anos, ele é primário e não cometeu o crime com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 44 do CP).

Na condenação superior a 1 ano, a substituição pode ser feita por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (art. 44, §2º, do CP).

Considerando que a sanção penal deve cumprir função pedagógica e social, cabível a aplicação de duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 01 salário-mínimo, a entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo juízo da execução, e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em estabelecimentos voltados à assistência social, saúde, ensino e congêneres ou em programas comunitários, a critério da unidade gestora e na forma a ser definida pelo juízo da execução (arts. 43, I e IV; 45 e 46 do CP; e art. 483 das NSCGJ).

Fica prejudicada a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar GABRIEL HENRIQUE DA SILVA à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito

previsto no art. 33, §§1º, III, e 4º, da Lei 11.343/06. Com fundamento nos arts. 44, §2º; 43, I e IV; 45 e 46 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade a ele aplicada por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 01 salário-mínimo, à entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo juízo da execução e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em estabelecimentos voltados à assistência social, saúde, ensino e congêneres ou em programas comunitários, a critério da unidade gestora e na forma a ser definida pelo juízo da execução.

Por não mais interessar ao processo, autorizo a destruição do entorpecente apreendido (art. 72 da Lei 11.343/06 e art. 524-A das NSCGJ). Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico (art. 524-A, §2º, das NSCGJ). Serve a presente como ofício.

Certificado o trânsito em julgado, determino a restituição do celular apreendido ao acusado, por, apesar de se tratar de instrumento do crime, não consistir em coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito (art. 91, II, a, do CP e art. 118 do CPP, interpretado a contrario sensu). Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico (art. 524-A, §2º, das NSCGJ). Serve a presente como ofício.

Custas pelos réus, observada a gratuidade de justiça.

O acusado responde ao processo em liberdade, não sobrevivendo motivos para sua segregação cautelar. Portanto, ele faz jus ao direito de recorrer em liberdade, salvo se por outros motivos deva ficar preso (art. 387, §§1º e 2º, do CPP).

Decorrido o prazo recursal, expeça-se certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 15, III, da Constituição e art. 398 das NSCGJ), a guia de recolhimento definitiva (art. 467 a 474 das NSCGJ), bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

Expedida a guia, ela deverá ser encaminhada ao Juízo da Execução mediante lançamento da movimentação "processo findo", com a situação "suspense" (art. 468, §3º, das NSCGJ), certificando-se nos autos.

Após, nada mais restando a deliberar, archive-se, fazendo-se as anotações necessárias no sistema informatizado (art. 184 das NSCGJ).

Saem os presentes intimados.

José Bonifácio, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA